문제 1. 노동계약 규제 입법의 필요성

법학입문 · 압축 답안

문제 사적자치와 계약자유의 원칙에도 불구하고, 계약공정의 관점에서 사인 간 노동(근로)계약을 규제하기 위한 입법이 필요한 이유를 구체적인 예를 들어 설명하시오.

서론

근대 사법은 **사적자치**(자기결정·자기책임)를 원리로 하며, 여기서 **계약자유**가 나온다. 이에 따르면 노동계약도 노무와 보수를 교환하는 민법상 고용계약(제655조)이므로 근로조건은 당사자 합의에 맡겨야 한다. 그런데도 국가가 근로기준법 등으로 합의 내용까지 통제하는 이유는 노동계약에서 **계약자유의 전제인 힘의 균형**이 무너지기 때문이다.

본론

계약자유가 정당한 근거는 당사자가 스스로 원했다는 **주관적 정당성**에 있다. 그러나 이는 당사자가 계약 내용을 이해하고 불리한 계약을 **거절할 수 있는 힘의 균형**을 전제로 한다. 이 전제가 무너지면 계약자유는 강자가 약자를 지배하는 수단이 되므로, 국가가 **객관적 정당성**의 관점에서 계약 내용을 통제해야 한다. 이것이 **계약공정의 원리**이다.

노동계약은 이 전제가 가장 뚜렷하게 무너지는 영역이다. 노동력은 사람의 몸과 인격에서 분리할 수 없는 **'허구 상품'**이고(폴라니), 생산수단이 없는 노동자는 노동력을 팔지 않으면 생존할 수 없어 사실상 **거절할 자유가 없다**. 계약을 맺은 뒤에도 노동자는 사용자의 **지휘·명령 아래 종속**된다. 그런데 민법의 고용 규정은 임의규정이고 제660조는 해고를 자유롭게 허용하며, 제104조의 불공정 법률행위는 요건이 엄격하고 계약 **전부를 무효**로 만들어 오히려 노동자에게 불리하다.

그래서 헌법 제32조 제3항은 근로조건의 기준을 **인간의 존엄성**에 맞게 법률로 정하도록 하고, 근로기준법은 **최저기준**(제3조)에 못 미치는 부분만 무효로 한 뒤 **법정 기준으로 채운다**(제15조). 예컨대 노동자가 동의한 최저임금 미달 약정도 미달 부분은 무효가 되고 최저임금액이 적용된다(최저임금법 제6조 제3항). 수당을 더 받으려고 동의한 장시간 노동도 건강과 생명을 해치므로 **주 52시간제**로 제한된다. "언제든 해고할 수 있다"는 조항은 **정당한 이유 없는 해고 금지**(근로기준법 제23조)에 반하며, 노동위원회와 법원이라는 공적 제3자가 이를 구제한다. **5인 미만 사업장 적용 제외**나 **중대재해처벌법** 같은 입법 쟁점도 같은 원리에서 판단해야 한다.

결론

노동계약 규제는 계약자유를 **부정하는 것이 아니라 회복**하는 것이다. 국가는 **최저기준**을 정하고 그 위는 노동3권에 기초한 **집단적 자치**에 맡겨 실질적 자기결정을 보장한다. "노동은 상품이 아니다"라는 원칙처럼, 계약공정은 결국 **인간 존엄**의 문제다.

문제 2. 양심적 병역거부: 구·신 결정 비교

문제 구 병역법 제5조 제1항이 양심적 병역거부자를 위한 대체역 복무를 정하지 않은 것이 헌법 제19조 양심의 자유 침해인지에 대한 (과잉금지원칙 심사에 따른) 헌법재판소의 구 결정과 신 결정을 비교하시오.

서론

구 병역법 제5조 제1항(병역종류조항)의 병역은 모두 **군사훈련을 전제**로 하여 대체역이 없었고, 거부자는 제88조 제1항(처벌조항)으로 처벌되었다. 쟁점은 이것이 **양심의 자유**, 특히 양심에 반하는 행동을 강요받지 않을 **부작위에 의한 양심실현의 자유**를 침해하는지이며, 기준은 **헌법 제37조 제2항의 과잉금지원칙**이다(문제의 "제1항"은 제2항이 정확함).

본론

구 결정(헌재 2004. 8. 26. 2002헌가1, 2011. 8. 30. 2008헌가22 등)은 처벌조항을 심판대상으로 삼아 **합헌**으로 판단했다. 헌법재판소는 양심의 자유를 국가에 양심을 '고려'해 달라고 요구하는 권리로 좁게 보고, 국가안보 분야에서는 입법자에게 **넓은 재량**이 있다며 완화된 심사를 했다. 목적의 정당성과 수단의 적합성을 인정한 뒤, 대체복무는 남북 대치 상황, 병력 손실, 양심 판정의 어려움, 형평성 문제 때문에 같은 효과를 보장하지 못하므로 **침해의 최소성을 충족**한다고 보았다. 또 국가안보라는 공익이 중대하므로 **법익의 균형성도 충족**한다고 했다. 다만 2004년 결정은 입법자에게 대체복무 도입을 검토하라고 **권고**했다.

반면 **신 결정**(헌재 2018. 6. 28. 2011헌바379 등)은 대체역을 두지 않은 **병역종류조항**을 직접 심사하여 **헌법불합치**를 선고했다(6:3). 목적과 수단은 정당하다고 보았지만, 양심적 병역거부자는 연간 수백 명에 불과하고 처벌을 받아도 어차피 수감되어 병력이 되지 않으며, 엄격한 심사와 현역보다 무거운 복무로 위장 거부와 형평성 문제를 해결할 수 있으므로 **침해의 최소성에 위반**된다고 판단했다. 또 공익은 대체복무로도 충분히 달성되는 반면 형사처벌과 전과 등 거부자의 불이익은 심대하므로 **법익의 균형성도 잃었다**고 보았다. 헌법재판소는 2019년 12월 31일까지 개선입법을 명했고, 처벌조항은 합헌(4:4:1)으로 유지했다.

두 결정을 비교하면, 구 결정은 입법재량을 존중하는 **완화된 심사**로 양심과 안보 가운데 하나를 고르는 **양자택일**의 구조를 취했다. 신 결정은 **엄격한 과잉금지 심사**로 대체복무를 통해 두 법익을 **조화**시키는 방향을 택했다. 그 결과 결론도 '합헌과 입법 권고'에서 '헌법불합치와 입법 명령'으로 바뀌었다.

결론

신 결정은 위헌성의 원인을 '처벌'이 아니라 **'대안 없는 입법'**에서 찾고, 양심과 안보를 **대체복무로 조화**시키도록 입법자에게 의무를 지웠다. 이후 대법원 전원합의체(2018. 11. 1. 2016도10912)가 양심적 병역거부를 '정당한 사유'로 보아 무죄로 판단했고, **대체역법(2019)**으로 36개월 대체복무가 도입되었다. 소수자의 양심을 보호한 진전이지만, 대체복무가 징벌적이지 않도록 **실질적 등가성**을 갖추는 과제가 남아 있다.

문제 3. 공법관계와 사법관계

법학입문 · 압축 답안

문제 공법관계와 사법관계의 의의와 양자의 차이점을 설명하시오.

서론

근대 법질서는 **국가와 사회(시장)를 구분**하고, 이에 따라 법도 사적자치를 원리로 하는 **사법**과 공익 실현을 원리로 하는 **공법**으로 나뉜다. 어떤 법률관계가 어디에 속하느냐에 따라 **적용 법규와 구제 절차**가 달라지므로 구별이 중요하다.

본론

사법관계는 대등한 사인 사이의 법률관계로, 사적자치가 적용되고 당사자의 의사 합치, 곧 계약으로 형성된다. 국가가 사인과 같은 지위에서 물품을 사는 **국고관계**도 사법관계에 속한다. 이에 비해 **공법관계**는 행정주체가 공권력이나 공익 실현의 주체로서 사인과 맺는 관계로, 법률에 근거하여 **일방적으로** 형성된다는 점이 다르다. 둘을 가르는 기준으로 이익설·종속설·신주체설이 있으나, 실제로는 관계 법규의 목적과 성질을 **종합**하여 판단한다. 예를 들어 같은 토지 취득이라도 협의취득은 사법상 매매이고, 수용재결은 공법상 처분이다.

양자의 차이는 다음과 같다. 사법관계는 **사적자치**가 원리이지만, 공법관계에서는 행정이 법률에 따라야 한다는 **법률적합성**과 비례·신뢰보호 같은 행정법의 일반원칙이 적용된다. 사법관계는 계약으로 자유롭게 형성되지만, 공법관계는 **처분**으로 형성되며 행정절차법의 절차를 지켜야 한다. 사인의 법률행위는 하자가 있으면 무효나 취소가 되지만, 처분은 **공정력과 불가쟁력**을 가진다. 의무를 이행하지 않을 때 사인은 스스로 강제할 수 없어 판결과 민사집행을 거쳐야 하지만, 행정청은 대집행이나 강제징수 같은 **행정상 강제집행**을 할 수 있다.

손해의 전보와 분쟁 해결 방식도 다르다. 사인의 불법행위는 민법 제750조로 배상하지만, 공무원의 직무상 불법행위는 **국가배상법**으로 배상하고, 적법한 공권력 행사로 특별한 희생이 생기면 헌법 제23조 제3항에 따라 **손실보상**을 한다. 분쟁은 사법관계에서는 민사소송법으로, 공법관계에서는 **행정소송법**(항고소송·당사자소송)으로 다룬다. 이익 조정에서도 사법관계는 신의칙과 권리남용 금지로 **대등한 사익**을 조정하는 반면, 공법관계는 과잉금지원칙과 본질적 내용 침해 금지의 틀에서 **공익과 사익을 형량**한다.

결론

오늘날 노동법·경제법 같은 **사법의 공법화**와 공법상 계약·행정사법 같은 **공법의 사법화**로 경계가 상대화되었다. 그러나 적용 법규·강제 수단·구제 절차가 여전히 다르므로 **구별의 실익**은 남아 있다. 공·사법의 구별은 사적 자율을 존중하면서 **공권력을 법으로 통제**하려는 법질서의 기본 설계다.